

1500110-12.2021.8.26.0123

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Éverton Willian Pona

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... instaurada para a apuração do delito de tráfico de entorpecentes.

Não há preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes

A materialidade da conduta imputada ao réu encontra-se devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 09-11), auto de exibição e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capão Bonito

Foro de Capão Bonito

2ª Vara

Rua Rafael Machado, 50, Capão Bonito-SP - cep 18304-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500110-12.2021.8.26.0123 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500110-12.2021.8.26.0123

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3009917/2021 - DEL.POL.CAPÃO BONITO,

16048630 - DEL.POL.CAPÃO BONITO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAMES DO CARMO CALIXTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Éverton Willian Pona

Vistos.

1 RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública, sob o rito ordinário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de JAMES DO CARMO CALIXTO, já devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Segundo consta na denúncia (fls. 45-47), no dia 22 de janeiro de 2021, por volta de 21:45 horas, na Rua Aurélio Monticeli, nº 540, Bela Vista, nesta cidade e comarca de Capão Bonito, JAMES, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 47 (quarenta e sete) eppendorfs de "cocaína" com massa bruta de 35,49g

(trinta e cinco gramas e quarenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com Ministério Público, o denunciado trazia consigo as porções de droga acima descritas, com a manifesta intenção de comercializá-las, fato que chegou ao conhecimento da Polícia Militar, através de denúncias populares.

De posse de tais informações, os policiais se deslocaram até o endereço acima descrito, onde encontraram JAMES, que possuía as características descritas pelos populares, deliberando por abordá-lo.

Em revista pessoal, encontraram 47 eppendorfs de cocaína em poder do denunciado, que foi prontamente conduzido à Delegacia de Polícia.

Deste modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente as denúncias populares, a quantidade e forma pela qual estavam embaladas as drogas, em porções individuais típicas do tráfico de rua, restou claro, para o Ministério Público, que o denunciado vinha traficando entorpecentes.

Acompanharam os autos deste processo o recebimento da denúncia às fls. 48-50, seguindo-se a regular citação do réu (fl. 59), com posterior apresentação de resposta à acusação (fls. 61).

Realizou-se audiência de instrução na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. Nada foi requerido na fase no art. 402, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa requereu a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal.

É o relatório. Passo à fundamentação e decisão.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal instaurada para a apuração do delito de tráfico de entorpecentes.

Não há preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes

A materialidade da conduta imputada ao réu encontra-se devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 09-11), auto de exibição e apreensão (fls. 03-04), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 38-41) e pela prova oral colhida em juízo.

Em relação à autoria, de se considerar que o réu, na fase policial, disse que: estava na rua de sua casa e foi abordado pelos policiais militares; estes encontraram em seu bolso a substância entorpecente; é usuário; comprou a droga na cidade de Sorocaba; nunca foi preso. (fls. 06).

Interrogado em juízo disse que: os entorpecentes apreendidos eram para seu consumo e os comprou em Sorocaba pois é mais barato.

A testemunha, Mario Juliano de Oliveira Takeshita, policial militar, ouvido em solo policial, disse que: receberam denúncias de populares que um indivíduo de bermuda preta e camisa de time, estaria traficando entorpecentes na Rua Aurélio Monticelli; se deslocaram ao local e encontraram tal indivíduo com as características informadas; ao realizar a abordagem, lograram êxito ao encontrar 47 eppendorfs em seu bolso de substância branca aparentando ser cocaína (fls. 05).

Em juízo relatou que: estavam em patrulhamento próximo ao local dos fatos quando populares deram a descrição de uma pessoa que estava realizando a traficância; foram até o local dos fatos e encontraram o réu, já conhecido dos meios policiais; abordaram o réu e encontraram as drogas (47 porções de cocaína); o réu admitiu que a droga era sua; não havia dinheiro com o réu; a esposa do réu já foi presa por tráfico.

A testemunha, Adriano Antônio de Proença, policial militar, ouvido em juízo relatou que: no dia dos fatos receberam denúncias de populares dando conta do tráfico no local; encontraram JAMES com os entorpecentes e ele disse que havia comprado em

Sorocaba e era usuário; o réu estava próximo a um bar .

No que tange ao depoimento de policiais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprir em seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”. (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No caso sob análise, a atuação dos agentes policiais revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Os depoimentos dos policiais foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados de credibilidade e com força probatória. Nada existe de concreto nos autos a indicar que os policiais ouvidos em juízo estivessem tentando incriminar falsamente o réu, atribuindo-lhe o falso cometimento de um delito.

Do contexto probatório dos autos extrai-se que JAMES alegou ser usuário de drogas e por isso continha as drogas consigo. Contudo, a quantidade de apreendida, associada aos depoimentos das testemunhas de que receberam denúncias de populares que não queria se identificar dando conta da ocorrência do tráfico indicam afastam a conclusão de que todo o entorpecente era destinado ao consumo do réu, que adquiriu a droga dois dias antes de sua prisão e essa circunstância, como questionado em audiência, causa estranheza. Se adquirida dois dias antes, não havia razão para estar com toda a droga consigo, na rua, dois dias depois. O consumo dessa quantidade poderia ser fatal.

Portanto, não há dúvida sobre a ocorrência do fato delituoso e de sua autoria.

O réu, de forma consciente e espontânea, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 47 (quarenta e sete) eppendorfs de “cocaína” com massa bruta de 35,49g (trinta e cinco gramas e quarenta e nove centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se amolda formalmente à previsão abstrata do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Com isso, resta preenchida a tipicidade formal.

Caracterizada, pois, a tipicidade formal objetiva, imperioso destacar a presença, também, da tipicidade material, ante a efetiva violação do bem jurídico protegido pela norma, bem como, dos elementos subjetivos do tipo. O réu agiu com dolo, nas modalidades cognitiva e volitiva, pois evidente tratar-se de conduta deliberada. O fato é típico, portanto.

Outrossim, não se verificam presentes quaisquer das causas excludentes da antijuridicidade da conduta, previstas no art. 23, do Código Penal. O fato descrito é, assim, típico e ilícito.

Além disso, o réu possui plena capacidade penal e pode ser responsabilizado por seus atos. É penalmente imputável e possui condições de compreender a ilicitude de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Segundo se observa nos autos, possuía conhecimento suficiente, à época dos fatos, para perceber a ilegalidade de sua ação e agir, se assim quisesse de outra forma. Optou pela conduta ilícita quando dele era exigível comportamento diverso. Por tais razões, a

sua conduta é culpável.

Desse modo, por se tratar de fato típico, antijurídico e culpável, ausentes quaisquer causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou de extinção da punibilidade, mostra-se imperiosa a condenação do réu JAMES DO CARMO CALIXTO nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

2.2 Individualização da pena

Fixadas tais premissas, passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas. Adota-se, para a dosimetria da pena, o sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

2.2.1 Dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria a culpabilidade mostra-se normal e inerente ao delito; não constam antecedentes; não há informações sobre a conduta social ou sobre a personalidade do réu; os motivos são inerentes ao delito, assim como as circunstâncias e as consequências. Não se observa, por fim, qualquer contribuição do comportamento da vítima.

No caso de tráfico de drogas, deverá ser considerado com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei de Drogas). Quanto à natureza, observa-se ter sido apreendida cocaína. Não há maior reprovabilidade quanto a essa circunstância. Em relação à quantidade, foram apreendidos 47 (quarenta e sete) eppendorfs de "cocaína" com massa bruta de 35,49g (trinta e cinco gramas e quarenta e nove centigramas). O montante já se mostra suficiente para ensejar maior reprovação, de modo que a circunstância deve ser considerada negativa.

Em relação ao quantum do aumento nesta fase da dosimetria prevalece na jurisprudência, em razão da ausência de previsão específica na legislação, competir ao magistrado sopesar as especificidades do caso concreto e atribuir o devido valor a cada uma das circunstâncias judiciais. Confirma-se:

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O CP não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 107.860, rel. min. Rosa Weber, 1ª T, DJE de 25-9-2012.)

O STF submete a legalidade da pena ao fundamentado exame judicial das circunstâncias do delito. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. O art. 59 do CP confere ao juízo sentenciante o poder-dever de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa. Sucede que, em situações como a retratada nos autos, o juiz sentenciante há de considerar parâmetros que são próprios da legislação de drogas. Parâmetros constantes do art. 42 da Lei 11.343/2006. Pelo que o caso é de calibração das balizas do art. 59 do CP com as circunstâncias listadas na pertinente legislação extravagante. No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da quantidade de droga apreendida. O que não discrepa da jurisprudência do STF (RHC 108.878, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, DJE de 21-11-2011).

Em reflexão sobre a forma de atribuição do quantum atinente a cada circunstância judicial, este magistrado entende, em aperfeiçoamento a posicionamentos anteriores, que a majoração da pena nesta fase da dosimetria em um percentual fixo (1/6 ou 1/8) sobre a pena mínima abstrata prevista na legislação ignora por completo a previsão legislativa acerca do limite máximo da reprimenda estabelecido, tratando de forma igual crimes com gravidade distintas, o que, em última análise, viola o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

Isso porque a individualização da pena apresenta-se em três momentos distintos: o legislativo (cominação abstrata da pena), com a fixação dos limites mínimo e máximo da pena; o judicial, com o estabelecimento da pena in concreto; e no momento da execução da pena, quando tem influência o comportamento individual do apenado para a concessão dos benefícios previstos na legislação.

A fase legislativa, de cominação abstrata da pena, representa a reprovabilidade do corpo social em relação à conduta tornada crime. Assim, no momento da aplicação, ignorar que crimes com a mesma pena base podem ostentar penas máximas distintas corresponde a sobrepor-se à reprovação da conduta externada pela sociedade por intermédio dos legisladores.

Desse modo, por serem 10 as circunstâncias constantes no caput do art. 59, do CP, somadas, entende-se que o quantum a ser atribuído a cada uma delas é de, no mínimo, de 1/10 entre a diferença da pena mínima e máxima fixada para o delito. Contudo, forte na jurisprudência, as especificidades do caso autorizam ao magistrado a atribuir maior relevância a uma ou outra circunstância, desde que devidamente fundamentado.

Considerando que no presente caso reconheceram-se duas circunstâncias como negativas (a quantidade da substância), acresço ao piso 1/10 da diferença entre o mínimo e o máximo abstratamente cominado ao delito e fixo a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, em relação às agravantes e atenuantes, observa-se não constarem quaisquer das situações ou circunstâncias previstas nos arts. 65 e 66, do Código Penal, nem daquelas elencadas nos arts. 61 e 62, do mesmo diploma, razão pela qual mantenho a pena provisória em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. Por fim, na terceira fase, considerando a primariedade do réu, a ausência de maus antecedentes e ao fato de não integrar organização criminosa, aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim, diminuo a pena em 2/3. Portanto, torno definitiva a pena em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa.

2.2.2 Regime inicial de cumprimento da pena

Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário esclarecer que o réu foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, o qual é equiparado ao hediondo e, por força do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da determinação por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, em 27/06/2012. Assim sendo, não há vedação à fixação de regime inicial diverso do fechado, mesmo a condenados por tráfico de drogas, consoante o entendimento do STF, por força da necessária individualização da pena, que implica na necessidade de se observarem as circunstâncias do caso concreto e de cada condenado.

Nos termos do art. 59, III, do Código Penal, considerando o requisito objetivo (a quantidade de pena fixada em 2 anos de reclusão), o fato de o réu não ser reincidente e tendo em vista as circunstâncias judiciais (art. 33, §3º, do CP), a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente aberto.

2.2.3 Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis

No caso o réu foi condenado a pena inferior a 4 anos, satisfazendo o requisito objetivo. Além disso, o condenado não é reincidente e as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal não lhe foram desfavoráveis. Sua conduta não se mostra incompatível com a vida em sociedade, já que o crime não afrontou a integridade física de outrem, pelo que faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP).

Tendo em vista a pena fixada, determino a substituição por uma restritiva de direitos consistente na prestação de serviço à comunidade (art. 44, §2º, do CP), a ser cumprida à razão de 1 hora por dia (art. 46, §3º, do CP).

2.2.4 Fixação do valor do dia-multa

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu.

2.2.5 Detração

A aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (detração a ser realizada pelo juiz na sentença) carece de uma melhor regulamentação, visto ser dispositivo assemelhado aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais.

Nesse sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação Criminal – Recepção. Sentença condenatória. Recurso Defensivo pleiteando o reconhecimento da detração para fixar o regime aberto para cumprimento da pena. Materialidade e autoria provadas - Réu surpreendido na condução de veículo produto de furto - Depoimento do policial que merece credibilidade, sendo coeso e harmônico em relação ao conjunto probatório - Confissão judicial do réu que corrobora as demais provas produzidas em juízo - Manutenção da condenação de rigor - Dosimetria das penas - Pena-base fixada no mínimo legal - Manutenção da compensação da circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por ausência de reclamo Ministerial - Entendimento predominante no sentido de que a reincidência prepondera sobre a confissão, nos termos do art. 67, do Código Penal - Vedação da reforma tio in pejus - Penas inalteradas - Regime inicial semiaberto que se mantém em razão da reincidência registrada - Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Detração da pena - questão que deve ser melhor analisada em sede de execução criminal - Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0068936-68.2016.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017)

Do teor do acórdão extrai-se:

No tocante a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos [...].

No mesmo sentido, recente julgado da 8ª Câmara Criminal do Tribunal Bandeirante, na Apelação nº 016797-87.2012.8.26.048, Relator: Lauro Mens de Melo, donde se extrai que, "inicialmente, inviável entender-se que o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal pode ser considerado como alteração de regime inicial a partir de pena cumprida, funcionando como progressão indireta". Além disso, "trazer para o processo de conhecimento numerosos dados acerca da execução tumultuária o processo, tornaria a prestação jurisdicional confusa e mais demorada, o que certamente vai de encontro aos interesses da defesa".

Com efeito, a progressão do regime por este juízo, em decorrência de custódia cautelar, requer o acesso a dados pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo. Ademais, a detração somente pode ser adequadamente apreciada pelo juízo da execução, que pode analisar todas as condenações do réu e evitar que o mesmo período de custódia cautelar seja utilizado para abatimento das penas em mais de um processo.

Tal análise deve ser feita no âmbito da execução penal, pelo que deixo de realizar a detração.

3 DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu

JAMES DO CARMO CALIXTO pela prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 200 dias-multa.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação.

FIXO valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENO o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP) e, com base no art. 15, III, da Constituição Federal, enquanto durarem os efeitos da condenação, DETERMINO a suspensão de seus direitos políticos.

4 DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Prisão preventiva

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, DEIXO DE DECRETAR a prisão preventiva, pois o réu foi condenado a pena a ser cumprida em regime aberto e a custódia cautelar seria mais rigorosa do que o próprio cumprimento da reprimenda.

4.2 Determinações finais e comunicações

Comunique-se a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ) e, com o trânsito em julgado:

- a) Intime-se o réu para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, do CP e art. 480, das NSCGJ), bem como das custas judiciais no prazo de 60 dias (art. 480, §1º, das NSCGJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento da multa no prazo assinalado, extraia-se certidão da sentença nos termos do art. 480-A, das NSCGJ;
 - b) Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ);
 - c) Expeça-se de guia de recolhimento definitiva ou oficie-se aditando a guia provisória (art. 472, das NSCGJ) e mandado de prisão;
 - d) Determino a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas e ainda não destruídas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006);
 - e) Comunique-se a SENAD, para o fim previsto no art. 63, §§ 2º e 4º, da Lei nº. 11.343/2006, remetendo relação dos bens e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, os locais em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente;
 - f) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
- Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Capão Bonito, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA